

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（二）

第五講

國民主權與國民大會

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

國民主權與國民大會

-- 釋字 499 號解釋剖析

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、國民大會的性質與定位

一、直接民主 v. 間接民主？

1. 「權能區分」說 (§25)

- 人民有「四權」v.

(四種政權：選、罷、創、複＝直接民權)

- 政府有「五能」

(五種治權：行政、立法、司法、考試、監察)

→ 五權分立，平等相維)

- 政權（人民的參政權利）v. 治權（政府的統治權力）

- 人民四權（利）如何駕馭政府五權（力）？

2. 國民大會是「政權機關」？

2.1 人民之「權利」≠ 國民大會之「權力」

如何使（民意）代表「但盡其能，而不竊其權」？

Ω 原擬以「直接民主」（四權）制衡「代議民主」政府（五能），詎「國民大會」質變為「治權」之一
i.e., 「權能區分」問題 → 「權力分立」問題！

國民大會亦「國會」（治權機關）？

Ω 釋字 76, 釋字 325（理由書）

Q 國大代表得兼任（其他）治權機關之成員？

Ω 釋字 30, 74 (禁止利益衝突原則)

v. 釋字 75 (制憲原意容許)

2.2 「國民」主權 ≠ 「國民大會」主權

• 五五憲草 §32 「國民大會之職權如左：

- 一、選舉總統副總統、立法院院長副院長、監察院院長副院長、立法委員、監察委員。
- 二、罷免總統副總統、立法、司法、考試、監察各院院長副院長、立法委員、監察委員。
- 三、創制法律。
- 四、複決法律。
- 五、修改憲法。
- 六、憲法賦予之其他職權。」

Q 中共全國人大沿襲？(Cf. 2004 中共憲法 §§62, 63)

- §25 「依本憲法之規定」，代表人民行使政權
→ §27 (選舉、罷免正、副總統；修改憲法)

二、國民主權原則與代議民主

1. (對內) 主權之意涵(sovereignty, Staatsgewalt)

- 1.1 「政治主權」(political sovereignty) = 選、罷、創、複
- 1.2 「立法主權」(legislative sovereignty) = 立法權能(力)
- 1.3 「議會主權」(「議會至上」) 原則

國民保有「政治主權」，國會行使「立法主權」

2. (對內) 主權歸屬與國家類型

2.1 人民主權(popular sovereignty)

人民擁有「政治主權」及「立法主權」

2.2 國民主權(national sovereignty)

人民擁有「政治主權」，國家機關擁有「立法主權」

2.3 國家主權(state sovereignty)

國家機關擁有「政治主權」及「立法主權」

民主國家(democratic state) v.

極權國家(totalitarian states)或威權國家(authoritarian states)

📖 湯德宗，〈直接民主的制度設計〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 257 以下（2014 年，增訂四版）

三、國民大會「代表」人民？

1. 命令的委任（委任代表）v. 自由的委任（法定代表）

📖 湯德宗，〈直接民主的制度設計〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 245 以下（2014 年，增訂四版）

❓ 前述分類似曾相識？

Ω 總統「委任直選」（類似美國「總統選舉人團」）

v. 總統「全民直選」的論辯？

2. 代議機關的組成界限

❓ 民意機關之成員能完全不由人民選舉產生？

Ω 釋字 499（政黨比例代表之比率有上限？）

3. 直接選舉 v. 間接選舉？

❓ 罷免也能由「代表」，代為行使（間接罷免）？

Ω 罷免、創制、複決乃「直接民主」之手段，只能由人民親力親為

四、國民大會定位演變

1. 憲法本文

- 「無形國大」（35/01/10 政治協商會議十二項）

- 「虛形國大」(35/03/16 國民黨二中全會)
 - 制憲妥協：國大不經常集會，為無給職代表
- 2. 臨時條款、第一次增修
 - 治權機關化(釋字 76)
- 3. 第二、三、四次增修
 - 朝「兩院制國會」邁進
 - 3.1 同意權 + 修憲權
 - 3.2 常設化(設置議長)
 - 3.3 代表有給職化
 - Q 國大何以終難成為國會第二院？
 - Q 我國應否建構兩院制國會？
- 4. 第五次增修
 - 改為全額政黨比例代表制(國大政黨機器化)
 - 增修 §1-I & 釋字 331；釋字 499
- 5. 第六次增修
 - 任務型國大(國大虛形化)
- 6. 第七次增修
 - 廢除國大(國大無形化)，還政於民
 - Q 何以有此戲劇性轉折？
 - Ω 國民主權意識覺醒

貳、國大代表的產生與任期

一、國大之選任(§26)

1. 名額

Q 國大名額應規定於憲法？

Ω 如何兼顧「彈性」與「明確」？(Cf. 1991 一次增修 §1)

2. 選舉

Q 何以採用混合式選舉（區域選舉 + 職業團體 + 婦女團體）？如何能兼顧「票票等值」（選舉平等）原則？

Cf. 1991 一次增修 §1

3. 全國不分區代表

Q 由來？

Ω 釋字 261（解釋理由書）

Q 作用？

Ω 兼顧理想與現實，並強化政黨控制

4. 婦女保障名額

Q 必要？合憲？

Ω 法律保障（§26-I-(7)）**v.** 憲法保障（1991 一次增修 §1-II）？

二、國大任期（§28）

1. 定性

Q 釋字 31：政府體制問題？人權（參政權）保障問題？

Q 釋字 85, 117

Ω 湯德宗，〈大法官有關「權力分立原則」解釋案之研析〉，輯於氏著，《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》頁 375（2014 年，增訂四版）
第一屆資深中央民意代表自願退職條例（78/02/03）

2. §28-II 與 §28-I

Q 矛盾？

Ω 釋字 21

Q 釋字 31 何以未言及「國大代表」？

Cf. 釋字 261 理由書[2]

3. 官吏不得在任所所在地當選國代 (§28-III)

Q 立意？

參、國民大會的職權與特權

一、國大職權 (§27)

1. 職權與定位

1.1 選舉總統

§27-I(1) → 2005 七次增修 §2-I (人民直選)

1.2 罷免總統

§27-I(2) → 2005 七次增修 §2-IX (立院提案 + 公民複決)

1.3 修改憲法

§§27-I(3) & 174-I(1) → 2005 七次增修 §§ 1 & 12 (廢除國大，改由立法院提案，交公民複決)

Q 何者門檻較嚴格？

1.4 複決修憲案

§27-I(4) & §174-I(2) → 2000 六次增修 §1-I & II-(1)
→ 2005 七次增修 §§1 & 12 (廢除國大，改由立法院提案，交公民複決)

1.5 創制、複決法律 (§27-II)

Q 何以附始期 (日出條款 sunrise provision) ？

Q §136 → 公民投票法 (92/12/31) (國民主權原則從此落實)

1.6 變更領土

§4 (決議) → 2000 六次增修 §1-II-(2) (複決立法院所提憲法修正案) → 2005 七次增修 §§1 & 4-V (廢除國

大，改由立法院提案，交公民複決）

Cf. 釋字 328

1.7 議決總統、副總統彈劾案

1994 三次增修 §1-III-(3)（監察院提案+國大議決）；

1999 五次增修 §1-V-(3)（立法院提案+國大議決）；

2000 六次增修 §1-II-(3)（立法院提案+國大議決）→

2005 七次增修 §§ 4-VII & 5-IV（立法院提案，交憲法
法庭審理）

1.8 聽取總統國情報告、檢討國是（1994 三次增修 §1-V）

Q 用意？

→ 2000 六次增修 §4-III（立法院得聽取總統國情報告）

Q 何以迄未實施？

2. 職權與待遇

無給職時期：

釋字 282

有給職時期：

釋字 299 →

國民大會代表報酬及費用支給條例（81/08/03）

3. 職權與兼職

Q 國大兼監委？釋字 15

Q 國大兼立委？釋字 30

Q 國大兼官吏？釋字 75

Q 釋字 30 與釋字 75 矛盾？

Q 議長不得兼職？釋字 421

Q 釋字 421 與釋字 75 矛盾？

二、國民大會之集會

1. 例會 (§29)

Q 何以不許自行召集？

Q 國大享有「議事自律」？

Ω 雖無議事自主 (§34)，仍可自律 (釋字 254 (理由書)；
釋字 381)

2. 臨時會 (§30)

2.1 召集

Q 何以仍不許自行召集？

Q 國大定位與自行集會之關係？

Ω 設置議長

1994 三次增修 §1-VIII；1997 四次增修 §1-VII

2.2 活動限制

Q 例會得行使臨時會之職權？

Ω 釋字 29

Q 臨時會得修憲？

Ω 釋字 314

3. 開會地點 (§31)

4. 程序他律 (§34)

Q 立意？

Q 1994 三次增修後「議會自律」之界限？

Ω 釋字 381 & 499

Q 兩者見解有無不同？

5. 宣誓

釋字 199, 254

Q 宣誓何以成為政治抗爭的焦點？

三、國民大會代表之特權(privilege)

1. 言論免責特權 (§32)

Q 目的？

Ω 釋字 401

2. 不受逮捕特權 (§33)

Q 何以限於「會期中」？

Q 何謂「現行犯」？

Ω 釋字 90

肆、釋字四九九號解釋解析

一、修憲之正當程序

1. 「公開透明原則」旨在「貫徹政治責任」

1.1 修憲案之讀會不適用無記名投票

Q 何以僅「修憲案讀會」不適用？(Cf. 釋字 381)

1.2 議事自律與無記名投票

Q 應禁止議會「無記名投票」？

2. 「程序公開透明」旨在「滿足理性溝通」

Q 何謂「思辨民主」(deliberative democracy)？

Q 程序「公開透明」即可滿足「理性溝通」？

Ω 其時國代獨佔修憲權，其他機關無從制衡，亦無「直接民主」(公投複決)可為制衡，有違權力分立原則。

- 美國憲法第五條：

修憲案須經參、眾兩院各三分之二議員通過始得提出，並經全國四分之三州議會之批准，始得生效。

- 德國聯邦基本法第七十九條第二項：

修憲案須經聯邦眾議院議員三分之二及聯邦參議

院投票權三分之二之同意。

同條第三項並明定「憲法修改之界限」。

- 法國第五共和憲法第八十九條：

修憲案須經國會兩院表決通過，並經公民複決同意，始告確定；或由共和國總統將修憲案提交國會兩院聯席大會議決，經獲聯席大會五分之三有效票同意，始得通過。

- 日本憲法第九十六條：

修憲案須經參、眾兩院全體議員三分之二贊成，提出於國民，並經特別之國民投票，或在國會所定選舉時所為之投票中，獲得過半數之贊成，始為通過。

3. 國會議事程序與違憲審查

3.1 「重大明顯瑕疵」理論（Cf. 釋字 342）

Q 關於國會議事程序，司法（違憲審查）應介入多深？

Q 釋字 342 & 499 之審查基準（審查密度）不同？

3.2 「議事自律」與「違憲審查正當性」

二、修憲的（實質）界限

1. 界限

1.1 「自由民主憲政秩序」＝ 憲法整體基本原則？

Q 誰來認定？

Q 違憲審查包含「修憲案是否合憲」之審查？

1.2 修憲應有（實質）界限？

1.3 「公民複決」亦有修憲界限？

Q 經公民複決之修憲案，屬「制憲」或「修憲」？

Ω 釋字 721（湯德宗大法官〈部分協同暨部分不同

意見書》)

三、全額比例代表制違憲

1. 違反 §25？或違反 §2（國民主權原則）？
2. 2000 六次增修仍採比例代表制，違憲？

四、當屆任期延長違憲

1. 違反「國民主權」原則？
Q 如何違反？如經人民「同意」即合憲？
2. 違反「利益（衝突）迴避」原則？
Q 如何違反？立委不也自定俸給？
3. 違反「自由民主憲政秩序」？
Q 如何違反？「自由民主憲政秩序」無所不包？

五、違憲效果

1. 1999 五次增修條文自本解釋「公布」之日起失效（嗣後立即失效）。
2. 原規定（前次增修條文）仍有適用

《對話憲法・憲法對話》2015

【學思策問】

Q 釋字 499 之貢獻？設若未有該解釋，於今？

Q 釋字 499 宣告 1999 五次憲法增修條文部分違憲的理由？其他論理（方式）亦可獲致相同結論？

【進階閱讀】

湯德宗，〈國大延任修憲疑義解釋案審查說明會意見書〉，輯於氏著，《違憲審查與動態平衡：權力分立新論·卷二》，頁 541～563（2014 年，增訂四版）。

Akhil R. Amar, *Popular Sovereignty and Constitutional Amendment*,

in *RESPONDING TO IMPERFECTION: THE THEORY AND PRACTICE OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT* 89 (Sanford Levinson ed., 1995).